

1501639-93.2022.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... translúcidas. Sendo o réu conhecido por tráfico e sendo possível ver pinos no interior da sacola, realizaram a apreensão de seu conteúdo (porções de cocaína), deram cumprimento ao mandado cível e fizeram a prisão em flagrante por tráfico.

Importante aqui salientar a fotografia de fls.34, deixando claro que era possível ver o conteúdo das embalagens, eis que translúcidas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501639-93.2022.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501639-93.2022.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON ROBERTO FAVARO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de processo-crime contra EVERTON ROBERTO FAVARO, já qualificado nos autos, como incurso no crime do art.33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Notificação às fls.179.

Defesa preliminar juntada às fls.183/186.

Recebimento da denúncia, às fls.191/192.

Citação às fls.213.

Em audiência foram ouvidas testemunhas e o réu, interrogado (fls.258/263).

As partes debateram (fls.264/265).

Ministério Público pediu a condenação nos moldes da denúncia.

Defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas e outros benefícios legais.

É a síntese.
DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão condenatória.

Materialidade demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 29 e laudo de fls.132/134.

A autoria é certa. Vejamos:

Interrogado, Everton Roberto Favaro admitiu que guardava as drogas apreendidas e que receberia verba em pecúnia como pagamento. Aduz dificuldades financeiras, inclusive em pagar pensão para filha menor. Afirma que as drogas estavam escondidas atrás de um agaveta, dentro do armário. Nega que estivessem sobre a cama, pois reside com seus pais e crianças frequentam a casa. Diz que não sabia o conteúdo exato da sacola recebida, mas sabia que era coisa "errada". Os policiais encontraram as drogas após revirar completamente o cômodo.

Em sentido diverso, os policiais civis Bruno Bertanha e Bruno Azzini relataram que o réu era conhecido pela prática de tráfico e esteve sob investigação por algum tempo. No dia dos fatos, receberam mandado de prisão por dívida alimentícia em desprol do denunciado e rumaram para seu fiel cumprimento. Ingressaram no imóvel e, em contato com os genitores do réu, souberam que ele estava a se banhar. O banheiro fica ao lado do quarto do acusado e, ao se dirigirem ao banheiro, avistaram sobre a cama do réu as drogas apreendidas, acondicionadas dentro de sacolas brancas translúcidas. Sendo o réu conhecido por tráfico e sendo possível ver pinos no interior da sacola, realizaram a apreensão de seu conteúdo (porções de cocaína), deram cumprimento ao mandado cível e fizeram a prisão em flagrante por tráfico.

Importante aqui salientar a fotografia de fls.34, deixando claro que era possível ver o conteúdo das embalagens, eis que translúcidas, o que será de vital importância para fundamentação acerca da inocorrência, in casu, de "fishing expedition".

No mais, a testemunha Bruna Oliveira da Silva disse nada saber sobre a prisão, esclarecendo que o réu fazia "bicos" e que seus filhos frequentavam a casa onde ocorreu a prisão. Não soube onde foram encontradas.

Silvio Roberto Favaro, genitor do acusado e ouvido como informante (sem compromisso de dizer a verdade), relatou ter presenciado a prisão e que os policiais reviraram o quarto do denunciado até encontrarem as drogas. O quarto teria ficado todo revirado, com objetos quebrados.

Jenifer Leandro, companheira do réu, ouvida como informante, disse que as drogas ficavam dentro de um armário e que os policiais reviraram tudo até encontrá-las.

São as provas.

A condenação é de rigor.

De fato, o réu confessou que guardava drogas para terceiro mediante remuneração, o que configura o delito de tráfico.

A alegação de que não sabia o conteúdo da sacola recebida não convence.

Com razão, a versão do denunciado, alegando ausência de dolo por não ter ciência do que havia dentro do pacote recebido de terceiro, mediante remuneração para guarda-lo, não merece guarida.

Com razão, aplicável "in casu" a teoria da "Willful Blindness Doctrine" (Doutrina da cegueira intencional), "Ostrich Instructions" (instruções de avestruz), "Conscious Avoidance Doctrine" (doutrina do ato de ignorância consciente) ou, no vernáculo, "Teoria da Cegueira Deliberada" ou "Teoria das Instruções da Avestruz".

Referida tese equipara a alta desconfiança ao conhecimento inequívoco, com reconhecimento, no mínimo, do dolo eventual.

Isso ocorre quando o agente assume o risco, de forma consciente, ao receber objeto sob sua guarda e que, dadas as circunstâncias peculiares, tenha condições de saber o seu conteúdo ou de, ao menos, desconfiar tratar-se de substâncias ilícitas.

Dentro destas hipóteses, incluem-se as condutas de "cegueira" ou "ignorância" deliberada, uma vez que o réu deveria ter agido com a devida cautela e se informado sobre o conteúdo do pacote que recebera sob sua responsabilidade.

Se o denunciado não tinha plena ciência (o que se admite apenas para fins argumentativos), ao menos ignorou propositalmente este fato, assumindo o risco (dolo eventual) de praticar o delito de tráfico.

Em suma, a versão do réu mostra-se inverossímil, caracterizando a "cegueira deliberada", na medida em que detinha meios de saber acerca da procedência do objeto que recebeu de terceiro, mas assim não agiu.

Isto é, preferiu correr o risco de incorrer em prática criminosa, o que importa, na verdade, em dolo eventual, suficiente à caracterização do tipo penal imputado na denúncia.

Afere-se, portanto, o ânimo subjetivo do agente, através da análise dos dados objetivos da conduta descrita e comprovada no processo.

Além disso, em casos desta estirpe tal qual ocorre no crime de receptação, o dolo, para que não dependa exclusivamente da confissão, deve ser extraído das circunstâncias fáticas (STJ AgRg no REsp 908826/RS rel. Min. Jane Silva j. 30/10/2008).

Assim sendo, não exige prova uníssona e indiscutível, mas sim uma prova que possa convencer o juiz, dentro do princípio da persuasão racional.

Viável, portanto, fundamentar-se, tal qual ocorre nos países de Common Law, condenação criminal quando o julgador estiver convencido beyond any reasonable doubt - além de qualquer dúvida razoável.

E nem poderia ser diferente. Exigir-se prova uníssona e indiscutível sobre circunstâncias subjetivas do agente - tais como dolo, ciência do conteúdo do pacote recebido etc - seria tornar letra morta a tipificação de condutas penais relevantes, eis que a condenação dependeria, como dito acima, exclusivamente da confissão do agente.

Não é, assim, imprescindível prova irrefutável de tal condição (prévia ciência do conteúdo do pacote recebido) - mesmo porque impossível -, mas apenas que as circunstâncias evidenciem não haver dúvida razoável de que o agente detinha tal

conhecimento, cabendo ao julgador analisar o contexto probatório.

Ademais, pela regra do ônus de prova, a simples apreensão, a posse da res pelo agente firma a presunção juris tantum contra ele do conhecimento clandestino, obrigando-o a justificar devidamente a posse, sob pena de não o fazendo, ser responsabilizado pelo crime de tráfico.

Refuta-se, ainda, a tese defensiva que busca a nulidade do feito com base na apreensão de drogas feitas quando do cumprimento de mandado de prisão, eis que ausente autorização para busca domiciliar.

Sobre o tema, recentemente o E. STJ deliberou que "(...) entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.(...)." (STJ, RHC 165982 / PR, 6ª. Turma, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, em 20/09/2022, DJe 26/09/2022).

No mesmo sentido:

"(...) Consoante recente orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito" (HC n. 663.055/MT, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). 2. Nessa linha de inteligência, não se pode admitir que a entrada na residência especificamente para o cumprimento de mandado de prisão sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade. 3. A existência de mandado de prisão em aberto para apuração de crime de homicídio supostamente praticado por dois dos pacientes não justifica a realização de buscas na residência da terceira paciente, em verdadeira pescaria/expedição probatória, procedimento que demanda autorização judicial expressa ou a autorização explícita e espontânea da ré, o que não ocorreu no caso. (...)." (STJ, AgRg no HC 733910/SC, 5ª. Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em 06/02/2022, DJe 13/09/2022).

Entretanto, a situação dos autos é diversa.

Isso porque, os testemunhos válidos dos agentes estatais (e aqui não há razão para desconfiança) é no sentido de que a droga estava sobre a cama e, sendo o plástico que a envolvia translúcido – o que é possível verificar pela fotografia de fls.34 - , não há falar-se em busca domiciliar.

De fato, os agentes ingressaram no imóvel para cumprimento de mandado de prisão, em horário permitido, o que dispensa autorização dos moradores, e ao se deslocarem para o banheiro, onde o réu estava, avistaram sobre a cama do denunciado as drogas apreendidas.

Não podiam, assim, até sob pena de prevaricação, fazer vista grossa e deixar de prender o denunciado.

Diferente seria se demonstrada a tese defensiva de que vasculharam o imóvel.

Nesse sentido, o ônus probatório é da defesa, parte que alegou ofensa à lei pelo agentes públicos.

Lembre-se que acerca as falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido:

“Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade.” (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

E mais: “O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp).

Não se está aqui a conceder poder total aos testemunhos dos policiais, mas apenas que, para desacreditá-los, é necessário elemento probatório palpável ou que suas declarações sejam contrárias ao bom senso (máximas de experiência), o que não se verificou nos autos.

Com efeito, a Defesa, apesar de alegar que o quarto foi revirado e que bens foram danificados, nenhum elemento concreto foi capaz de trazer aos autos. Nenhuma singela fotografia foi juntada e os informantes ouvidos (genitor e companheira) são, por lei, parciais e não prestam o compromisso de dizer a verdade.

Válido aqui mencionar que o defensor é constituído pelo réu desde a fase policial e esteve presente no interrogatório de fls.08, sendo certo que poderia, se verídica a versão, ter orientado os familiares do denunciado a fotografar o quarto após a diligência policial.

Refutada, pois, por falta de provas a tese defensiva.

Igualmente não convence a tese de estado de necessidade.

Nesse diapasão, o réu alega estar passando por dificuldades financeiras, tanto que havia contra ele mandado de prisão por pensão alimentícia.

Todavia, dificuldades não significam necessariamente estado de necessidade.

Nesse sentido, transcrevo:

“Dificuldade de subsistência por meios lícitos decorrentes de doença, embora grave, não justifica apelo ao recurso ilícito, moralmente reprovável e socialmente perigoso, de se entregar o agente a negociação de tóxicos” (JUTACRIM 25/214).

Ora, o réu morava em local compatível com a dignidade humana, estando bem alimentado, ainda que com ajuda de familiares. Logo, não precisava traficar para sobreviver.

Além disso, como se sabe, “A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156 ...). Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência

do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais (...)" (Curso de Processo Penal, 20a. Edição, ed. Saraiva, 2013, CAPEZ, Fernando, p. 410) .

Entretanto, importante ressaltar que "a prova da acusação há de ser plena e convincente, enquanto que para o acusado basta a dúvida, já que tem por si a presunção de inocência. Dispõe, com efeito, o art. 386, VI, do Código que o juiz absolverá o réu "se não existir prova suficiente para a condenação" (BARAUNA, José Roberto. Lições de Processo Penal, 2a. Edição, editora José Bushatsky. São Paulo, 1979, p. 1255)

Assim sendo, uma vez alegado o estado de necessidade, caberá à Defesa demonstrar a concorrência de seus requisitos ou condições ou, ao menos, gerar dúvida razoável sobre sua existência. São eles:

"Quatro condições, perante o Código vigente, são indispensáveis: a) existência de perigo atual para um interesse juridicamente protegido; b) não ter esse perigo sido provocado voluntariamente por quem invoca a justificativa; c) inevitabilidade do perigo; d) proporcionalidade entre a conduta do agente, ao salvar o direito, e a natureza do perigo que se lhe deparava" (GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal. Vol I. Tomo I, 4a. Edição, 22a. Tiragem. Editor Max Limond. São Paulo, p.292).

Contudo, no caso em apreço, nenhuma das condições acima restou evidenciada pelos elementos probatórios dos autos. Os indícios aventados pelo agente sequer ensejam dúvida quanto a existência de estado de necessidade foram capazes de fazer emergir.

Logo, inviável acolher-se mencionada tese defensiva.

Por fim, irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

De fato, tratando-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado - que, segundo o Professor Damásio de Jesus, "são crimes em que o tipo faz referência a várias modalidades da ação" - o delito estará consumado com a prática de um ou mais de um dos verbos nucleares" (Direito Penal, 10. Volume, Parte Geral, 6a. Edição, editora Saraiva, 1980, p. 200)

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câmb., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que "para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des.

Denser de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Passo a dosar a pena.

O réu ostenta maus antecedentes (autos 7397-21.2008). Aumento a pena em 1/6.

O acusado confessou, razão pela qual a pena deve retornar ao mínimo legal.

Os maus antecedentes impedem o redutor do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

O regime inicial é o fechado por conta dos maus antecedentes.

Inviável substituição ou suspensão condicional da pena por conta da vida pregressa.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão estatal para CONDENAR o réu EVERTON ROBERTO FAVARO, já qualificado nos autos, como incurso no crime do art.33, "caput", da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

Custas em 100 UFESPs. Mantida a prisão processual para garantia da ordem pública, em razão dos antecedentes do condenando.

Determino a destruição das drogas e perdimento do numerário apreendido. Anotem-se. Comuniquem-se. Providencie-se o necessário, com urgência.

Oportunamente, arquivem-se.

Araras, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA